

1505158-88.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... que o réu não confessou o crime de tráfico de entorpecentes, não preenchendo destarte o requisito objetivo. Disse ser usuário, logo, não confessou a acusação. Ademais o delito de tráfico de drogas é mola propulsora de inúmeros outros delitos e, portanto, embora não tenha violência ou grave ameaça a pessoa, entendo que a medida no caso concreto não é suficiente a prevenção e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505158-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505158-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENAN DE OLIVEIRA LIMA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 05 de abril de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, a Advogada, Dra. Iracilda Xavier da Silva Almeida, OAB/SP, nº 275.877 e o acusado; RENAN DE OLIVEIRA LIMA, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação

audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas policiais; Robson Alves da Silva Rodrigues e Murilo Vilela de Carvalho. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: Meritíssimo Juiz, o réu RENAN DE OLIVEIRA LIMA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 c.c. art. 61, II, j do Código Penal, porque, no contexto descrito na denúncia, no dia 01 de março de 2022, por volta das 11h23min, durante reconhecido estado de calamidade, na Rua João Alves Pimenta, n. 767, Freguesia do Ó, nesse Município e Comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 60 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada "Cocaína" em material sólido petrificado, vulgarmente conhecido como "Crack", com peso de 6,5g, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação de fls. 13/15, e laudo de exame químico toxicológico que será oportunamente juntado, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Devidamente notificado, o réu ofereceu defesa preliminar, sendo que a denúncia foi regularmente recebida (fls. 71/74). O réu foi devidamente citado. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. PRELIMINARMENTE, entendo que não é caso de aplicação de acordo de não persecução penal. Verifica-se primeiro que o réu não confessou o crime de tráfico de entorpecentes, não preenchendo destarte o requisito objetivo. Disse ser usuário, logo, não confessou a acusação. Ademais o delito de tráfico de drogas é mola propulsora de inúmeros outros delitos e, portanto, embora não tenha violência ou grave ameaça a pessoa, entendo que a medida no caso concreto não é suficiente a prevenção e reparação do dano causado pelo delito. Portanto, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, inviabilizando o benefício. Por fim, ressalvo, por amor ao debate, que a denúncia já foi recebida (fls. 97/98), ficando superada a aplicação do benefício, nos termos de recente entendimento da 5ª Turma do STJ: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA 5ª TURMA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A Lei n. 13.964/2019 (comumente denominada como Pacote Anticrime;), ao criar o art. 28-A do Código de Processo Penal, estabeleceu a previsão no ordenamento jurídico pátrio do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP). 3. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. (HC-191.464/STF, 1ª TURMA, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2020). No mesmo sentido: (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/8/2020 e Petição no AREsp 1.668.089/SP, da Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe de 29/6/2020). 4. No caso dos autos, a discussão acerca da aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) só ocorreu em sede de apelação criminal e no momento do recebimento da denúncia não estava em vigência a Lei nº 13.964/2019, o que impede a incidência do instituto. 5.

Habeas corpus não conhecido. (HC 607.003/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)." Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 05/06, auto de exibição e apreensão de fls. 11, bem como pelo laudo de constatação de fls. 13/15 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls.128/130, que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, bem como pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, interrogado, o réu negou a acusação. Disse que adquiriu os entorpecentes par seu próprio consumo (fls.05). Em juízo, o réu negou a acusação de tráfico, afirmando que é usuário de drogas há 10 anos.

A negativa dos fatos pelos réus não convence e restou isolada das demais provas. Vejamos. Ouvida na fase inquisitiva os policiais militares disseram que realizavam o patrulhamento na região dos fatos, conhecido local de tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado RENAN, o qual ao ver a viatura jogou um objeto ao solo tentou evadir-se. Diante da atitude suspeita, decidiram por abordá-lo. Em revista pessoal, encontraram em poder do denunciado a quantia de R\$80,50 (oitenta reais e cinquenta centavos), assim como, as drogas supramencionadas, as quais estavam caídas ao solo. Indagado, o acusado confessou informalmente que praticava o tráfico de drogas e que o dinheiro apreendido era fruto do comércio ilícito de estupefacientes. Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao denunciado e conduzido ao distrito policial. Em juízo, o policial MURILO narrou que estavam patrulhando quando entraram na Avenida e Renan estava próximo a um local com entulho e, ao ver a equipe tentou se esconder. Abordaram Renan que estava com uma lata de cerveja na mão. Ele tentou se desvencilhar, jogando celular e uma caixinha de M&M. Tiveram que contê-lo porque ele estava muito agitado e neste tubinho havia pedras de crack. Não foi encontrado mais anda e ele foi conduzido ao DP. Era em torno de 60 pedras de crack, divididas e prontas para venda no varejo. O policial ROBSON em juízo corroborou o depoimento de seu colega e disse que o réu confessou que estava traficando, foi achado dinheiro e cerca de 60 pedras de crack, num tubinho, estavam acondicionadas num tubinho. A rua que ele estava é frequentada por usuários de entorpecentes. É um terreno baldio com matagal alto onde alguns usuários comparecem para usar drogas. Não foram encontrados com ele apetrechos usados para consumo de drogas. Ele estava bem maltrapilho. depoimento dos policiais, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão e quantidade de estupefacientes evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade

da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso... A bem da verdade os que sustentam o teratológico "recebimento com ressalvas" do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho... Não se pode

compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: "O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos" (TJSP - AC 205162-3/4 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT733/566). Desta forma, restou evidente que a acusação incumbiu-se de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento. No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de estupefacientes, nos termos do art. 59 do CP. Já na segunda fase, observo a agravante da calamidade pública do art. 61, II, "j" do CP. Finalmente, na terceira e derradeira fase, verifico causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de drogas. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado. Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de "graça, anistia e fiança", relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por "hediondos" - seja na sua forma tentada ou consumada -, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda "lavar" o dinheiro obtido, depositando-o na conta de "laranjas" fielmente associados às referidas organizações criminosas. demais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes disseca todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo

1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), "a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Não há dúvidas, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Portanto, em sendo considerado hediondo, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, RENAN DE OLIVEIRA LIMA, já qualificado nos Autos da Ação Penal em epígrafe, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência por intermédio da advogada que ao final esta subscreve, apresentar: MEMORIAIS DE DEFESA. I - Da Síntese Fática. O acusado encontra-se preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06 c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP. Segundo consta da peça flagrantial, na data de 01 do mês de Março de 2022, na sede do Plantão Policial do 13º D.P. CASA VERDE Distrito Policial, policiais militares compareceram naquela Distrital conduzindo o ora indiciado RENAN DE OLIVEIRA LIMA, tendo como CONDUTOR E PRIMEIRA TESTEMUNHA o policial ROBSON ALVES DA SILVA RODRIGUES, declinando que,; " Que, na data de hoje, encontrava-se de serviço com a viatura M 18117, em companhia de seu colega de farda, Murilo Vilelam de Carvalho; Que, por volta de 11:23 horas, encontravam-se em patrulhamento de rotina, pelas imediações da Rua João Alves Pimenta; Que, o local é conhecido por ser frequentado por usuários de substâncias entorpecentes; Que, na altura do número 767 havia um indivíduo, este ao perceber a aproximação da viatura policial, jogou um objeto ao solo, tentando disfarçar e deixar o local; Que, imediatamente veio a ser abordado pelo depoente; Que, inicialmente o indivíduo negou-se a ser revistado, debatendo-se, sendo necessário o uso de esforço físico, para contê-lo e, algemá-lo; Que, verificando o objeto ao solo, encontraram uma embalagem de março de cigarro e, no interior desta a quantia de R\$ 80,50 (oitenta reais e cinquenta centavos); Que, espalhadas ao solo haviam 60 (sessenta) pequenas pedras, semelhantes à substância entorpecente conhecida por "crack", bem como um telefone celular, marca Multilaser; Que, inquirido o indivíduo, identificado como Renan de Oliveira Lima, confessou o comércio das substâncias e, que a quantia era de origem de vendas; Que, nesta Unidade as substâncias foram apreendidas em auto próprio e, encaminhadas à perícia, onde os senhores peritos constataram tratar-se da substância entorpecente conhecida por "cocaína". O policial militar MURILO VILELA DE CARVALHO, indagado, às perguntas respondeu: "Que, o depoente é policial militar; Que, na data de hoje, encontrava-se de serviço com a viaura M 18117 e, por volta de 11:23 horas, encontravam-se em patrulhamento de rotina, pelas imediações da Rua João Alves Pimenta; Que, na altura do número 767 havia um indivíduo, este ao perceber a aproximação da viatura policial, jogou um objeto ao solo, tentando disfarçar e deixar o local; Que, imediatamente veio a ser abordado pelo colega do depoente; Que, inicialmente o indivíduo negou-se a ser revistado, debatendo-se, sendo necessário o uso de esforço físico, para contê-lo e, algemá-lo; Que, verificando o objeto ao solo, encontraram uma embalagem de março de cigarro e, no interior desta a quantia de R\$ 80,50(oitenta reais e cinquenta centavos); Que, espalhadas ao solo haviam 60(sessenta) pequenas pedras, semelhantes à substância entorpecente conhecida por "crack", bem como um telefone celular, marca Multilaser; Que, inquirido o indivíduo, identificado como Renan de Oliveira Lima, confessou o comércio das substâncias; Que, nesta Unidade as substâncias foram apreendidas em auto próprio e, encaminhadas à perícia, onde os senhores peritos constataram tratar-se da substância entorpecente conhecida por "cocaína". RENAN DE OLIVEIRA LIMA, interrogado, cientificado pela Autoridade Policial quanto aos seus direitos individuais constitucionalmente previstos, em especial os de receber assistência de familiares ou de advogado que indicar, de não ser identificado criminalmente senão nas hipóteses legais, de ter respeitadas suas integridades física e moral, de manter-se em silêncio e/ou declinar informações que reputar úteis à sua autodefesa, de conhecer a identidade do autor de sua prisão e, se admitida, prestar fiança, às

perguntas respondeu: Que, o interrogado informa ser viciado em substância entorpecente conhecida por "crack"; Que, narra que a substância encontrada em sua posse, veio a comprar de um desconhecido; Que, entregou um telefone celular, marca Samsung, este que pegou de sua irmã, bem como a quantia de R\$ 80,00(oitenta reais) em espécie; Que, as substâncias iria consumir; Que, nega que iria vender; Que ,foi surpreendido por policiais militares com as substâncias e, trazido a esta Unidade; Que, não possui outra passagens policiais". Remetido os Autos para o Plantão Judiciário o Douto Magistrado, após manifestação das partes converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelo artigo 33 da Lei 11.343/06. Posteriormente, o Douto Representante Ministerial denunciou RENAN DE OLIVEIRA LIMA como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal. EIS O BREVE RELATO. Recebida a denúncia, foi réu regularmente citado, apresentando resposta a acusação, não sendo o caso de absolvição sumária, seguiu-se a instrução, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 05/04/2022, ouvindo-se duas testemunhas de acusação e, ao final foi o réu interrogado. Em debates a Douto Representante Ministerial requereu a procedência da presente nos exatos termos da denúncia, com o que a defesa não concorda, vez que é o caso de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Os policiais militares ouvidos na fase judicial esclareceram como se deu a abordagem do acusado, ressaltando que este estava completamente agitado, dando mostras de que estaria sob o uso de entorpecentes, não havia nenhum outro usuário próximo a ele, bem como as drogas estariam acondicionadas dentro de um tubo de plástico tipo MM. O réu por sua vez, declinou ser usuário de crack há cerca de 10 anos, começou com um tipo de droga mais leve (maconha), porém com o passar do tempo, passou para o famigerado uso do crack. Mostrou suas mãos com a ponta dos dedos amareladas, característica de quem de fato é usuário de crack. Por fim declinou que antes de se tornar usuário, trabalhou no ramo de hotelaria exercendo a função de cozinheiro, tendo perdido tudo na vida por força desse maldito vício, inclusive ressaltando que já passou por cerca de 10 clínicas para dependentes químicos. ADARGUMENTANDUM TACTUM: convém assinalar, neste ponto, que, "embora aludido ao preso, a interpretação da regra constitucional deve ser no sentido de que a garantia abrange toda e qualquer pessoa, pois, diante da presunção de inocência, que também constitui garantia fundamental do cidadão [...], a prova da culpabilidade incumbe exclusivamente à acusação" (ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, Direito À Prova no Processo Penal, p. 113, item nº. 7, 1997, São Paulo: Revista dos Tribunais). De igual modo a doutrina de maneira uníssona ampara o acusado: "O processo criminal é o que há de mais sério neste mundo. Tudo nele deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza algébrica. Nada de ampliável, de pressuposto, de anfíbológico. Assente o processo na precisão morfológico legal e nesta outra precisão mais salutar ainda. A VERDADE SEMPRE DEVE SER DESATIVADA DE DÚVIDAS. (CARRARA).Entretanto, é velho princípio de lógica judiciária: A acusação não tem nada de provado se não conseguiu estabelecer a certeza da criminalidade, ao passo que a defesa tem tudo provado se conseguiu abalar aquela certeza, estabelecendo a simples e racional credibilidade, por mínima que seja, da inocência. As obrigações de quem provar a inocência são muito mais restritas que as obrigações de quem quer provar a criminalidade (F. MALATESTA – A Lógica das Provas – Trad. de Alves de Sá – 2ª Edição, pgs. 123 e 124). Nesse mesmo passo, mister se faz trazer a colação o ensinamento do mestre, Ministro Edson Vidigal, uma das vozes mais eloquentes e acatadas do STJ em defesa da liberdade e do princípio da inocência: "Até quando vamos ficar nessa hipocrisia de mandar acusados para a cadeia quando não há vagas nem para sentenciados?... "A restrição provisória à liberdade de um acusado, na ordem constitucional vigente, é exceção excepcionalíssima... Um preso caro aos bolsos do contribuinte: dinheiro que não se paga, na maioria dos municípios brasileiros, a três professores do primeiro grau... Dinheiro para moradia, comida, dormida, roupa lavada e banho de sol, e qual o retorno econômico e social disso, se a cadeia nada lhes acrescenta de bom, não os reeduca, não os redime?... É só para o imaginário popular escorrer saliva pelos cantos da boca e pensar que se está fazendo justiça? Mas que justiça?... " Sem dúvida, a realidade tem demonstrado, como ponderou Noé Azevedo, que 'por mais vem intencionados que sejam os juízes

profissionais, o exercício continuado da função de julgar vai produzindo certo amortecimento da sensibilidade, conduzindo a uma apreciação material e quase mecânica das causas, com graves prejuízos para o acusado. O contato diário com a fraude, com a mentira, com o embuste, com a falta de sinceridade de inúmeros acusados, começa a produzir um grande ceticismo no espírito do juiz em face dos protestos de inocência – e acaba convencendo-o de que todos os indiciados são culpados. Desse modo, quando se apresenta um denunciado perante um velho magistrado, este não procura encaminhar o interrogatório das testemunhas e a colheita das provas no sentido de demonstrar a inocência, e sim no de fazer ressaltar a culpabilidade. A presunção comum da inocência transforma-se, no seu espírito, em presunção geral de culpabilidade. (...) (in Laércio Pellegrino, Vitimologia, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 23/24). A propósito da prova, trazemos a colação o entendimento dos doutrinadores e da jurisprudência: “É melhor absolver um culpado do que condenar um inocente” (ROBERTO LYRA). “Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente” (Nelson Hungria). “A condenação exige certeza. Não basta sequer a alta probabilidade”. Não é possível, observa FRAGOSO, fundar sentença condenatória em prova que não conduz à certeza... Como ensina o grande mestre EDERHARDT SCHIMDT (“Deutsches Strafprozessrecht”, 1967, p. 48), constitui princípio fundamental do processo o de que o acusado somente deve ser condenado quando o Juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza... Se subsiste ainda apenas a menor dúvida, deve o acusado ser absolvido... A condenação exige certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade... (Jurisprudência Criminal”, III, BORSOI, 1973, PP. 405/406). Reafirmando esse princípio fundamental da teoria da prova, o STM, no julgamento da AC 39.012, relator o eminente Min. Alcides Carneiro, assentou: “A prova, para autorizar uma condenação, deve ser plena e indiscutível, merecendo dos julgadores o maior rigor na sua apreciação, mormente quando se trata de testemunhas marcadas pela dúvida e pela suspeição, geradas pelo interesse em resguardar situações de comprometimento pessoal”. Ressalta-se, por oportuno, que a condenação exige certeza absoluta, quer do crime quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquele. A certeza é aqui a *conscientia dubitandi secura* de que falava VICO e que não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e autoria (SAUER. *Grundelagem des Prozessrechts*, 1929, p. 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção insuficiente (HELENO FRAGOSO. *Revista de Direito Penal* – vol. 5.148, Editora Borsói). Preleciona o jurista SILVA LEME “a íntima convicção, sem apoio em dados ou elementos subjetivos indiscutíveis, leva à simples crença e não àquela certeza necessária e indispensável à condenação. Essa certeza não pode ser, igualmente, a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. A certeza que pode e deve levar à condenação é aquela de que todos devem participar, alçada sub espécie *universalis*.” Como diz JEAN PATARIN, citado por HELENO FRAGOSO, no trabalho acima referido (p. 149): “A procura da certeza perfeita revela-se uma exigência particularmente imperiosa do direito penal”. Certeza é sinônimo manifesto de evidente, de indiscutível, como o magistério do insigne jurisconsulto CARRARA: “No processo criminal máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica”. Compete à acusação demonstrar o elemento subjetivo da culpa, que há de ser plena e convincente, ao passo que para o Acusado basta a dúvida. É a consagração do *in dubio pro reo* ou *actore non probante absolvitur réus*; há prevenção legal da inocência do Acusado. É o que o Código expressamente consagra no art. 386, VI: “absolver-se o réu quando não existir prova suficiente para a condenação”. No tocante a prova do tráfico a jurisprudência atualizada assim entende: Prova precária. Absolvição decretada. (TJSP, Ap. Crim. 213.603-3, 2ª Câ. Crim., j. 30-9-1996, rel. Des. Renato Talli, JTJ 184/313). “Se a prova dos autos não gera a certeza de que a substância entorpecente apreendida pela polícia realmente pertencia ao acusado da prática do crime de posse, impõe-se a absolvição do mesmo com adoção do princípio do *in dubio pro reo*” (TJMG, Proc. 1002401099985-2, 3º Câ. Rel. Des. Paulo Cezar Dias, DJMG de 5-11-2004, Revista Magister de Direito Penal e Processo Penal, n. 2, p. 115).

Embora exista no texto da lei, a não concessão da liberdade, o STF, tem decidido em sentido contrário, vejamos: O Supremo Tribunal Federal - STF parece caminhar no sentido de unificar entendimento reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogras) no tocante à vedação da concessão de liberdade provisória à pessoa presa por tráfico de drogas. Em decisão que concedeu liminar nos autos do HC 100959-MC/TO (j. em 08/10/2009, p. no DJE de 15/10/2009), o ministro CELSO DE MELLO deixou bem clara esta tendência, conforme a seguir transcrito (Fonte: Informativo nº 571 do STF): Mesmo que se pudesse superar esse obstáculo, a afirmação do E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - fundada, tão-somente, no art. 44 da Lei nº 11.343/2006 - também não se revestiria de idoneidade jurídica, para efeito de justificação do ato excepcional de privação cautelar da liberdade individual. Mostra-se importante ter presente, no caso, quanto à Lei nº 11.343/2006, que o seu art. 44 proíbe, de modo abstrato e "a priori", a concessão da liberdade provisória nos "crimes previstos nos art. 33, 'caput' e § 1º, e 34 a 37 desta Lei". Cabe assinalar que eminentes penalistas, examinando o art. 44 da Lei nº 11.343/2006, sustentam a inconstitucionalidade da vedação legal à concessão de liberdade provisória prevista em mencionado dispositivo legal (ROGÉRIO SANCHES CUNHA, "Da Repressão à Produção Não Autorizada e ao Tráfico Ilícito de Drogas", "in" LUIZ FLÁVIO GOMES (Coord.), "Lei de Drogas Comentada", p. 232/233, item n. 5, 2ª ed., 2007, RT"; FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS, "Crimes de Uso Indevido, Produção Não Autorizada e Tráfico Ilícito de Drogas - Comentários à Parte Penal da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006", "in" MARCELLO GRANADO (Coord.), "A Nova Lei Antidrogras: Teoria, Crítica e Comentários à Lei nº 11.343/06", p. 113/114, 2006, Editora Impetus"; FRANCIS RAFAEL BECK, "A Lei de Drogas e o Surgimento de Crimes 'Supra-hediondos': uma necessária análise acerca da aplicabilidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/06", "in" ANDRÉ LUÍS CALLEGARI e MIGUEL TEDESCO WEDY (Org.), "Lei de Drogas: aspectos polêmicos à luz da dogmática penal e da política criminal", p. 161/168, item n. 3, 2008, Livraria do Advogado Editora", v.g.). "A experiência mostrou que a prisão, ao contrário do que se sonhou e desejou, não regenera: avilta, despersonaliza, degrada, vicia, perverte, corrompe e brutaliza" (Min. Evandro Lins e Silva). DIANTE DO EXPOSTO REQUER: A desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para o crime previsto no artigo 28 do referido Diplo Legal, por ser medida de Direito e Justiça! A experiência mostrou que a prisão, ao contrário do que se sonhou e desejou, não regenera: avilta, despersonaliza, degrada, vicia, perverte, corrompe e brutaliza" (Min. Evandro Lins e Silva). Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. RENAN DE OLIVEIRA LIMA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 01 de março de 2022, por volta das 11h23min, durante reconhecido estado de calamidade, na Rua Joao Alves Pimenta, n. 767, Freguesia do Ó, nesse Município e Comarca de São Paulo, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito, 60 pedras da substância entorpecente conhecida vulgarmente como "Crack", com peso líquido de 6,5g, além de R\$80,50 em dinheiro e um aparelho de telefonia celular, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudo de constatação de fls. 13/15, e laudo de exame químico toxicológico de fls. 128/130, oportunidade em que foi preso por policiais militares que desconfiaram das suas atitudes. A prisão preventiva foi decretada. O réu foi intimado e apresentou a sua defesa preliminar. A denúncia foi recebida no dia 01 de abril de 2022 (fls. 183/184). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado. Também foram juntados diversos documentos. Ao final da instrução, a acusação pediu a condenação e a defesa a desclassificação do crime para posse de drogas para o próprio uso. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque houve negativa expressa por parte do Ministério Público. II. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos (laudo pericial fls. 128/130), oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que

elas eram "Cocaína" (BENZOILMETTILECGONINA), na forma de pedra, conhecida vulgarmente por "Crack". A materialidade do crime está provada. III. A ação penal é parcialmente procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos depoimentos colhidos, interrogatório do acusado, quantidade de entorpecentes e a própria circunstância que envolveu a detenção do réu, não se estabeleceu certeza quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes por parte dele. Ao contrário, pela própria condição do acusado de usuário de drogas, somado ao fato de que não há qualquer imagem dele vendendo drogas e não foi detida qualquer pessoa que tenha comprado drogas dele, apresenta-se mais crível a posse de entorpecentes para o próprio uso do que o tráfico de drogas. Inclusive, as pontas dos dedos do acusado mostram sinais do uso de "Crack", bem como os policiais disseram que ele estava sob efeito de drogas quando foi preso. Embora o acusado não estivesse portando um invólucro para usar o "Crack", não é comum observar traficantes embriagados e os entorpecentes juntos sem uma embalagem individual para a venda no varejo. Portanto, existindo uma dúvida razoável sobre o réu ser traficante ou mero usuário, o caso é de desclassificação para a imputação de posse de entorpecentes para o próprio uso, observando-se o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal e a manifestação das partes. Considerando as peculiaridades do presente caso, o fato do réu ser primário, bem como estar preso provisoriamente, fixo a medida de prestação de serviços para a comunidade pelo prazo da prisão provisória como a adequada para os fins da lei. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a ação penal para após desclassificar a conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para o crime de posse de entorpecentes para o próprio uso, condenar RENAN DE OLIVEIRA LIMA, RG/SP nº 47254994, nascido em 05/07/1990, natural de São Paulo - SP, filho de Roberto Alves de Lima e de Maria Inês de Oliveira Lima, à medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da prisão cautelar, ou seja, por 34 dias, como incurso nas sanções do artigo 28, da Lei Federal nº 11.343/06. Condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita em razão da sua situação econômica. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Oficie-se para a destruição de todo o entorpecente que tenha sido guardado para contraprova, uma vez que há laudo pericial definitivo não impugnado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados para efeito de controle. O valor apreendido não teve a sua origem lícita demonstrada, motivo pelo qual determino o perdimento para a Secretaria Nacional Antidrogas. Após o trânsito em julgado da sentença, venham os autos conclusos para a extinção da punibilidade pelo cumprimento da medida imposta. Publicada a sentença em audiência, pelas partes e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer. Nada Mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital